

Nr. 95 Reichsjustizminister Gürtner an Reichsminister Lammers. 25. April 1938*R 43 II/1523a, Bl. 174–175 Ausfertigung**Beginn:**Beginn:***[Neuregelung des Rechts der Errichtung von Testamenten und Erbverträgen]**

Sehr verehrter Herr Kollege,

In letzter Zeit ist wiederholt beobachtet worden, daß die Rechtsprechung auf dem Gebiete des Testamentsrechts zu unbefriedigenden Ergebnissen führt. Mit Recht hat u. a. ein Beschluß des Kammergerichts vom 3. Februar d.J. lebhaftes Aufsehen erregt, durch den ein Testament lediglich deshalb für nichtig erklärt wurde, weil die Ortsangabe auf dem vom Erblasser benutzten Bogen vorgedruckt und nicht handschriftlich wiederholt war¹. Dem Kammergericht wird man wegen dieses Beschlusses keinen Vorwurf machen können; das Gericht war sich der Unbilligkeit des Ergebnisses bewußt, sah sich aber durch die *zwingende* Vorschrift des Bürgerlichen Gesetzbuchs, wonach alle wesentlichen Teile, auch Ort und Zeit, des Testaments eigenhändig geschrieben sein *müssen*, gebunden. Ein entscheidender Gesichtspunkt war vor allem aber der, daß bei Preisgabe einer seit Jahrzehnten vertretenen Auslegung eine große Zahl von Erbscheinen, die in ähnlichen Fällen im Laufe der Jahre ausgestellt worden sind, sich nachträglich als unrichtig erwiesen hätten. Die Folge wäre gewesen, daß zahlreiche längst erledigte Erbstreitigkeiten wieder hätten aufgegriffen werden können. Daher konnte hier nicht der Richter, sondern nur der Gesetzgeber helfen.

Der Beschluß des Kammergerichts hat gezeigt, daß die Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs über die Errichtung von Testamenten dringend einer sorgfältigen Überprüfung und weitgehenden Änderung bedürfen. Ich habe daher angeordnet, daß die Arbeiten an einem seit längerer Zeit vorbereiteten Gesetzentwurf zur Neuregelung unseres Testamentsrechts mit besonderer Beschleunigung betrieben werden².

¹ Im fraglichen Fall hatte der Hamburger Kaufmann Friedrich I. seine Braut Lilly H. durch eigenhändiges Testament auf dem Briefbogen seiner Firma, in den die Ortsangabe eingedruckt war, zur Alleinerbin bestimmt. Nach dem Tod des schwer lungenkranken I. erwirkten seine drei Halbgeschwister unter Berufung darauf, daß dieses Testament wegen Formfehlers nichtig sei (§ 2231 BGB), die Erteilung eines Erbscheins für sich. Frau H. legte dagegen Beschwerde ein und bekam vom LG Hamburg Recht zugesprochen, das am 27. 11. 1937 urteilte, die Ortsangabe sei dem Vordruck „müheles und zweifelsfrei“ zu entnehmen, und es widerspreche „der obersten Rechtsquelle heutiger Gesetzesanwendung, dem gesunden Volksempfinden“, wenn bloße Formfehler dazu führten, den eindeutigen Willen des Erblassers zu verfälschen; s. DJ 1938, S. 199 f. Auf erneute Beschwerde der Halbgeschwister hob das Kammergericht diesen Beschluß wieder auf, indem es das zwingende Erfordernis einer eigenhändigen Ortsangabe bestätigte: „Wohl ist das Volksempfinden als wichtigster Auslegungsbehelf auch bei der Frage zu berücksichtigen, ob einer Formvorschrift genügt ist, nicht aber als ein Mittel zu verwerten, den in einer klaren zwingenden Vorschrift niedergelegten Gesetzeswillen beiseite zu schieben. *Die Formen haben eine Gemeinschaftsbedeutung und verbürgen die Sicherheit des Rechtslebens.* Daraus folgt, daß, wenn eine Verletzung im Einzelfall Härten mit sich bringt, diese hingenommen werden müssen.“ Zu diesem Urteil s. DJ 1938, S. 428 f. Eingehend zu Vorgeschichte, Inhalt und Bedeutung des TestamentsG: L. GRUCHMANN, Die Entstehung des Testamentsgesetzes vom 31. Juli 1938. Ns. „Rechtserneuerung“ und Reformkontinuität, in: Zeitschrift für neuere Rechtsgeschichte 7 (1985), S. 53–63; J. SCHLIEPKORTE, Entwicklungen des Erbrechts zwischen 1933 und 1953, Jur. Diss. Bochum 1989, S. 131–164.

² Der erste, auf Vorarbeiten des Erbrechtausschusses der ADR fußende und von MR Vogels konzipierte Referentenentw. eines „Gesetzes über die Errichtung von Testamenten“ lag im März 1938 vor. Eine Neufassung als „Gesetz über die Errichtung von Testamenten und Erbverträgen“ war den beteiligten Ressorts (StdF, RIM, AA, REM, OKW, RStH Österreich) am 23. 4. zugegangen, mit Einladung zu einer Besprechung am 10. 5. im RJuM. Hauptüberlieferung: R 3001/20507; Abdruck beider Entwürfe: SCHUBERT, Familien- und Erbrecht, S. 299–313. Materialsammlung zur Erbrechtsreform: R 3001/20501–20503.

Der Fehler der bisherigen Regelung besteht namentlich darin, daß beim eigenhändigen Testament die Angaben über Ort und Zeit der Errichtung als Wesenserfordernisse angesehen werden, während sie doch in der Regel nur von untergeordneter Bedeutung sind.

In dem Gesetzentwurf ist daher folgende Lösung vorgesehen: Für die Gültigkeit des eigenhändigen Testaments genügt es, daß der Erblasser seine Erklärung eigenhändig schreibt und unterschreibt; die Beifügung einer Orts- oder Zeitangabe ist zwar erwünscht (Sollvorschrift); die Gültigkeit des Testaments wird aber nicht berührt, wenn die Orts- oder Zeitangabe nicht handschriftlich geschrieben oder unrichtig ist oder ganz fehlt³. Diese Angaben bilden also nach dem Entwurf nicht mehr den Gegenstand einer Mußvorschrift, sondern nur noch einer Sollvorschrift, deren Nichtbeachtung für die Aufrechterhaltung des Testaments unschädlich ist.

Der Entwurf sieht ferner Erleichterungen für die Unterschrift des eigenhändigen Testaments und für die Abfassung des gemeinschaftlichen eigenhändigen Testaments⁴ und darüber hinaus eine weitgehende Milderung der Formenstrenge auch beim öffentlichen Testament vor. Das Gesetz soll gleichzeitig auch auf Österreich erstreckt werden. Sobald unser Testamentsrecht in dieser Weise verbessert ist, wird eine Wiederholung der eingangs erwähnten unbefriedigenden Fälle unmöglich sein. Ich hoffe den Entwurf noch im Laufe des kommenden Monats der Entschließung des Reichskabinetts unterbreiten zu können⁵.

³ GesEntw. § 19 *Eigenhändiges Testament*: „(1) Der Erblasser kann ein Testament in ordentlicher Form durch eine eigenhändig geschriebene und unterschriebene Erklärung errichten.

(2) Der Erblasser soll in der Erklärung angeben, an welchem Ort und an welchem Tage er sie errichtet hat.

(3) Die Unterschrift soll den Vornamen und den Familiennamen des Erblassers enthalten. Unterschreibt der Erblasser in anderer Weise, etwa lediglich mit dem Vornamen oder durch Angabe der Familienstellung (Beispiel: Euer Vater) und reicht diese Unterzeichnung zur Feststellung der Urheberschaft des Erblassers aus, so steht eine solche Unterzeichnung der Gültigkeit des Testaments nicht entgegen.

(4) Wer minderjährig ist oder Geschriebenes nicht zu lesen vermag, kann ein Testament nicht nach obigen Vorschriften errichten. [...]“

⁴ Nur zulässig für Ehegatten: hierzu GesEntw. § 24 (2): „Zur Errichtung eines gemeinschaftlichen Testaments nach § 19 genügt es, wenn einer der Ehegatten das Testament in der dort vorgeschriebenen Form errichtet und der andere Ehegatte durch eigenhändige Mitunterzeichnung zum Ausdruck bringt, daß das Testament auch als sein Testament gelten soll. Die Erklärung des mitunterzeichneten Ehegatten soll die eigenhändig geschriebene und unterschriebene Angabe enthalten, an welchem Ort und an welchem Tage er seine Erklärung abgegeben hat.“ – Bislang schrieb § 2267 BGB zwingend vor, daß der mitzeichnende Ehegatte außer seiner Unterschrift auch Tag und Ort eigenhändig einsetzte und vermerkte, daß dieses Testament auch als sein eigenes gelten sollte; GRUCHMANN (o. Anm. 1) S. 53 f.

⁵ Lammers trug das Schreiben am 30. 4. 1938 Hitler vor (Anhang, FV 243*), der am Vorhaben des RJuM umso weniger auszusetzen hatte, als er zur selben Zeit sein eigenes Privattestament abfaßte und sich über den jurist. Formalismus hierbei echauffierte; s. GRUCHMANN (o. Anm. 1) S. 55 f.; Testament abgedr. in: UuF XI, Nr. 2590a. Die Verabschiedung dauerte aber doch länger, als Gürtner erhoffte: Als den Ressorts nach der Besprechung vom 10. 5. 1938 (o. Anm. 2) am 14. 5. ein revid. GesEntw. zugestellt wurde, bemängelten RKIM und RIM daran eine allzu große Formenlaxheit, welche den Charakter des Testaments als feierl. letztwillige Verfügung verwische, beide Ressorts und der RFSS zudem, daß der Entw. keine „Beschränkungen und Grenzen der Testierfreiheit im Interesse der Familie und der Volksgemeinschaft“ enthalte (RIM an RJuM, 2. 6. 1938); R 43 II/1523a, Bl. 179–199; SCHUBERT, Familien- und Erbrecht, S. 320–341. In der Folge wurde neu ein § 48 eingefügt, wonach eine Verfügung von Todes wegen nichtig war, (1) „soweit sie gegen zwingende gesetzliche Vorschriften verstößt“, (2) „soweit sie in einer gesunden Volksempfinden gröblich widersprechenden Weise gegen die Rücksichten verstößt, die ein verantwortungsbewußter Erblasser gegen Familie und Volksgemeinschaft zu nehmen hat“, (3) „soweit ein anderer den Erblasser durch Ausnutzung seiner Todesnot zu ihrer Errichtung bestimmt hat.“ SCHLIEPKORTE (o. Anm. 1) S. 150–159. In dieser Form stellte der RJuM dem RMRk am 21. 6. 1938 die KabVorl. zu, deren Annahme im schriftl. Beschlußverfahren Lammers am 15. 7. konstatierte. Hitler fertigte das *Gesetz über die Errichtung von Testamenten und Erbverträgen* am 31. 7. 1938 aus (RGBl. I S. 973); s. Anhang, FV 422*. Abdruck: SCHUBERT, Familien- und Erbrecht, S. 288–299. Amtl. Begründung: DJ 1938, S. 1254–1259; Kommentar: PFUNDTNER/NEUBERT II b 49, S. 11–38. Die Vorschrift des § 39, wonach letztwillige Verfügungen zur Vermeidung der „Verdunkelung der Erbfolge“ im Original an das Nachlaßgericht abzuliefern waren, wurde 1941 auf Druck des RMVP und der Partei-Kanzlei für die Fälle gelockert, in denen testamentar. Verfügungen in den letzten Briefen Gefallener an ihre Angehörigen enthalten waren; hierzu R 3001/20749, Bl. 240–317. Im übrigen galt das TestamentsG nach 1945, lediglich unter Streichung des § 48 (2), ohne sachl. Änderungen fort.

Lilly H., deren Fall die Erbrechtsnovelle angestoßen hatte, kam mangels Rückwirkung des Gesetzes nicht in seinen Genuß. Am 31. 9. 1938 wandte sie sich in einem Handschreiben an Hitler und gab vor, sie habe seinerzeit nicht zuletzt deswegen auf ihrem Erbspruch bestanden, um das Vermögen „nicht in die Hände eines Geschäftspartners meines Verlobten fallen zu lassen, der Jude und tschecho-slowakischer Staatsangehöriger ist“. Die Behauptung erwies sich als haltlos, Frau H. erhielt aber „in Rücksicht auf die besonderen Umstände Ihres Falles“ von Lammers im Jan. 1939 aus Verfügungsmitteln Hitlers eine Zuwendung von 3000 RM. Einen gerichtl. Vergleich in eben dieser Höhe hatte sie im Okt. 1937 ausgeschlagen. R 43 II/1523a, Bl. 222–251.

Heil Hitler!
Ihr sehr ergebener
Dr. Gürtner

Zitierhinweis

Nr. 95 Reichsjustizminister Gürtner an Reichsminister Lammers. 25. April 1938 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band V/1938, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).
<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh05d095>